

1502239-85.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 4586-8111, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502239-85.2021.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 4586-8111, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502239-85.2021.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

SILVIO ROMEIRO DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 14h28min, na Rua Professor Oscar Augusto Gueli Filho nº 365, Jardim do Lago, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, agindo em concurso com outra pessoa não identificada, transportava, para fim de tráfico, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, substâncias estas que causam dependência física e psíquica,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro no local dos fatos quando se depararam com o veículo GM Corsa, placa CDZ 2201, ocupado por duas pessoas, entre os quais o acusado, que ocupava o banco do passageiro.

Ao avistar a viatura, o condutor do automóvel empreendeu fuga, mas acabou perdendo o controle do automotor e colidiu contra o veículo Renault Oroch, placa FOA 3097, que estava estacionado no local.

Em seguida, os agentes deixaram o carro e empreenderam fuga. Os indiciados lograram êxito em prender o acusado e, em buscas no interior do automóvel, localizaram, no assoalho ao lado do passageiro, 235 porções de "crack", 60 porções de cocaína e 1 tablete de maconha.

Assim, pela quantidade das substâncias entorpecentes e circunstâncias das apreensões, foi preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Analisada a defesa apresentada, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, ouviram-se duas testemunhas.

Realizada audiência em continuação, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça analisou a prova e pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Requereu, ainda, a observância da reincidência do acusado, da grande quantidade de tóxico apreendida e a imposição de regime inicial fechado.

A defesa, em preliminar, arguiu a ilicitude das provas, tendo em vista a ilegalidade da revista pessoal. No mérito, bateu-se por absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para o édito condenatório. Para tanto, alegou que a negativa ofertada pelo réu deve ser considerada como elemento probatório. Sustentou, ainda, que as versões dos policiais são contraditórias e devem ser analisadas com reserva, ante o interesse que têm em justificar sua conduta. Em caso de entendimento diverso, requereu o que segue: fixação da pena-base no patamar legal; imposição de regime inicial diverso do fechado, com aplicação da detração penal e o direito de recorrer solto.

RELATADO.

DECIDO.

A preliminar não merece guarida.

Com efeito, não há falar em nulidade na abordagem do réu realizada pelos policiais militares, considerando que são eles imbuídos do poder de polícia que é próprio do Poder Público.

Sendo assim, quando esses agentes abordam qualquer cidadão em local público e dentro dos limites legais, respeitando os direitos daquele submetido à revista pessoal, não há que se falar em nulidade, vez que se trata de atitude que faz parte da obrigação legal dos agentes da autoridade. Além do mais, esses agentes não podem se omitir diante de qualquer situação em que se vislumbra eventual prática de crime.

Nesse teor, "(...) 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. 5. De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, "revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016). 6. No caso em exame, o acórdão impugnado afirmou que "tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto naquele posteriormente efetivado em juízo, houve expressa menção acerca da advertência do direito ao silêncio", razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo

Penal, segundo o princípio *pas de nullité sans grief*, o que não se verifica na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC nº 385.110/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/06/2017).

Não há, portanto, nulidade ou irregularidade na abordagem policial que ensejou a presente ação penal.

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por ventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios.

Oportuno, ainda, frisar que "em processo penal, vigoram os princípios de que 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)" (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

Diante da prova existente verifica-se que a denúncia deve ser julgada procedente. A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 51/53 e 117/119), provisório e definitivo, os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica e pelos demais documentos acostados aos autos.

Incontrovertida a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu preferiu o silêncio. Em Juízo, negou, dizendo que apenas pegou uma carona. O motorista do veículo que ocupava estava de "saidinha" e, por isso, assustou-se ao avistar a viatura policial e empreendeu fuga. Não tinha conhecimento que havia drogas no interior do automóvel.

Sucedu que tal negativa, seguida de versão inverossímil, restou isolada nos autos e não merece credibilidade.

Fortalecendo a prova de autoria, as testemunhas Hegen Henrique da Silva Oliveira e Cristiane Rodrigues Cardoso, policiais militares que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu o encontro das substâncias tóxicas em poder do réu. Explicaram, ainda, que o motorista do veículo ocupado pelo réu perdeu o controle do mesmo e colidiu contra outro automóvel. Após a colisão, o réu e o motorista correram a pé, tomando direções opostas. Conseguiram interceptar o acusado, que negou a propriedade do tóxico, mas afirmou que trabalhava em uma "biqueira" e não soube explicar o motivo de ter tentado fugir. As drogas foram encontradas no assoalho do banco do passageiro, onde Silvio estava sentado. Não conheciam o réu antes dos fatos.

E as palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação.

Além do mais, trata-se de depoimentos coerentes, harmônicos e verossímilantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova.

E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente o acusado que não conheciam, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido, "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

A testemunha Alex, arrolada pela defesa, disse que teve seu automóvel atingido pelo carro ocupado pelo acusado e não chegou a ver o encontro das drogas, nada mais esclarecendo sobre os fatos.

Note-se, agora, que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e

acondiçionadas em porções, para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

Dessa forma, insubsistente a alegação da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Concluindo, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu SILVIO ROMEIRO DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, no percentual de 1/4 (um quarto), somando 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, tendo em vista que possuidor de maus antecedentes, demonstrando que possui personalidade distorcida e incorrigível (fls. 102/105), além da quantidade de entorpecentes apreendida.

Note-se que a "Quantidade e qualidade da droga apreendida é circunstância que deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006" (cf. STF, 2ª Turma, RHC 111.440/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-094, 15/05/2012).

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, majoro a sanção em 1/6 (um sexto), resultando 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) diárias.

Não é caso de aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do acusado, o que demonstra sua dedicação ao crime.

A pena privativa de liberdade ora aplicada será cumprida em regime fechado, uma vez que se trata de crime gravíssimo, eis que a real intenção do traficante é amealhar o maior número de vítimas, comprometendo toda a sociedade.

Observe-se, por oportuno que mesmo a fixação da pena-base no mínimo legal cominado a espécie não é fator determinante para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Analisando a última parte do artigo em comento "estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" tem-se que o regime inicial fechado é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato, uma vez que a conduta do acusado colocou em risco, não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de toda a sociedade.

O réu não poderá apelar em liberdade, eis que presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Determino o perdimento do dinheiro em favor da FUNAD.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra.

Inaplicável o instituto da detração penal ao réu, conforme dispõe a Lei nº 12.736/12, ante as circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, a conduta social, os antecedentes e a personalidade do agente e, ainda, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade.

Ao incluir o § 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, não revogou o artigo 33, § 3º, do Código Penal, nem tampouco o artigo 59, inciso III, do mesmo Códex.

E, no caso concreto, as circunstâncias judiciais são efetivamente desfavoráveis para a fixação de regime inicial menos gravoso.

Assim, não obstante o previsto no artigo 387, § 2º, da Lei nº 12.736/2021 e, "data vênica" dos entendimentos contrários, bem como sendo impossível a este Juízo sopesar

a presença dos requisitos subjetivos, incabível a aplicação da detração penal. Nesse sentido, "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTENTE - PLEITO DE DETRAÇÃO - REGIME INICIAL FIXADO ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM O ARTIGO 59 DO CP C/C ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Caracteriza-se a omissão quando a Decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante. 2 - Não há omissão a ser sanada, na medida em que esta Colenda Câmara enfrentou detidamente todas as questões levantadas no apelo interposto, tendo apreciado de forma suficiente a pretensão deduzida, embasando seu entendimento na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3 - O regime inicial de cumprimento da pena não levou em consideração o critério objetivo da pena, mas sim o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal. c/c o artigo 42 da Lei de Drogas. 4 - O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória em razão de haver outras circunstâncias que sustentam a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5 - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00030386020128080047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, DJ 10/10/2014). Incabível, portanto, a detração penal ao sentenciado, cabendo ao Juízo da Execução a sua aplicação. Assim, fica o réu SILVIO ROMEIRO DA SILVA ALVES, condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) diárias, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados. P.I.C.

Jundiaí, 09 de fevereiro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito